

一、宪法的分类

类型化：法学认知的重要方法

(一) 传统的分类

1. 成文宪法与不成文宪法

(1) 标准：是否具有统一的法典

成文宪法：具有成文法典

不成文宪法：无法典，宪法渊源由宪法性法律、判例、惯例构成 代表国家：英国

(2) 分类的意义：

成文或不成文代表着宪法规范的集中程度

成文宪法国家相对集中，但也存在多元化的宪法渊源

成文宪法内容明确（体系化）、可操作性强，人权容易得到保障？）

不成文宪法国家独特的立宪史（英国革命的历史）

2. 刚性宪法与柔性宪法

(1) 标准：修宪程序、修宪机关与普通法律的异同

柔性宪法 与普通法律无异（英国 魏玛宪法） 刚性宪法 与普通法律不同 绝大多数国家是刚性宪法

(2) 对刚性宪法、柔性宪法的评价

柔性宪法容易修改，可以缓解矛盾甚至消弭战争，灵活性，妥协性

妥协是政治斗争的条件 立宪主义的包容精神需要妥协 传统社会的政治斗争由于缺乏宪法的整合，导致缺乏妥协精神 成王败寇

刚性宪法：稳定性、容易建立和平稳定的刚性宪法秩序，树立宪法权威

过于柔性或者过于刚性均对宪法秩序产生不利 希特勒频繁修改宪法最终废止

前者：频繁修宪，宪法权威受损，宪法秩序不稳

后者：难以协调多元化局面，或成为一国革命或战争的原因 如：1791年法国宪法

(3) 钦定宪法、协定宪法与民主宪法

标准：制定主体——政治力量对比关系

钦定宪法：君主，至上而下的改革

协定宪法：君主和人民协商制定的宪法

民主宪法：通过革命制定宪法

(二) 现代分类

1. 名义宪法、语义宪法与规范宪法

美国宪法学者罗文斯坦《现代宪法论》

(1) 标准：宪法实际上发挥的对国家权力的控制和规范作用——实效性（effacy）

规范宪法：西方法治成熟国家

宪法发挥了对国家权力的良好的规范、控制作用 权力完全服膺于宪法 宪法生活在国家、社会的怀抱之中

名义宪法：从欧美引进宪法制度的农业社会国家、殖民地国家

宪法的权威被确立，宪法的效力由于实施宪法政治条件的缺失（民众宪法意识、社会政治经济条件），宪法不能发挥其实效性 宪法政治的潜伏期

语义宪法：僭主政治下的宪法，前苏联、东欧等社会主义国家

当权者的宣传、点缀工具 缺乏实质的立宪主义精神 “遮羞布” 掩盖专制

(2) 分类的意义：效力与实效性：认知模式 事实与价值的二分

指向实施宪政的社会、历史、文化、经济条件

2. 社会主义宪法与资本主义宪法

前者：以巴黎公社宪法思想、苏联宪法为源流；公有制 民主集中制 议行合一；先锋队理论

后者：孟德斯鸠、洛克的政治宪法理论，自由主义，个人主义

权力分立与制衡、民主、人权、法治

中国宪法：有前者底色，吸收后者内容 磨合过程

(反对三权分立)

中国坚持党的领导 先知先觉者引领
作用 训政普通大众

二、宪法的历史

(一) 域外宪法历史

类型史：历史上存在过的各种宪法的典型特征及其关系

中国教科书上的国别史：一般关注美、德、日、法、英等国

1. 固有宪法：关于统治机关组织和权力的法律

罗马法中的组织法：必须有护民官的参加才能修改，而普通法律行政长官即可修改

中世纪：教会权力与世俗权力的分权结构，没有中国式的大一统权力结构

2. 近代立宪主义宪法

(a) 世界上最早的宪法

“五月花号”约章 美国联邦宪法 1787 年 法国 1791 年宪法

英国的一系列宪法性文件：从 1215 的大宪章到 1689 年的《权利法案》——最早的宪法
政治肇始于英国

(b) 近代立宪主义宪法的特征

(1) 近代立宪主义精神的基本结构

a. 控权与分权

“信任导致专制，民主是建立在猜疑的基础上的”——西方宪政文化中的“不信任主义”

b. 以自由权为基础的权利保障

三大自由权：精神自由、人身自由、经济自由 (宪法保护自由的核心内容)

消极防御国家：消极自由 自由放任体制：“管得最少的政府就是最好的政府”

小政府、大社会

c. 形式平等权（机会平等） 比如阿根廷的改革

反对实质平等 与放任自由的体制相一致

“所谓平等，就是指法律在保障或处罚时，对所有的人一视同仁”——法国《人权与公民权利宣言》

(2) 权力分立制

对立法、行政和司法三权进行划分，明确界限

a. 立法权 议会的存在一制定规则

民意的体现、国家意志，“本质是为了保障平等”

不得针对个案（特定事件、特定人）立法

预算、税收的立法主义——财政立宪主义

b. 司法权（法院）

解决纠纷：将抽象的、一般的法律规范适用于具体的、个别的案件

消极、中立、被动、不告不理（例外：发生在法官眼皮底下的犯罪）当地抓告

司法独立：法治的基本要素 宪法原则一保障权威性与公正性

c. 行政权 (依法行政)

政府的权力 执行法律“无法律则无行政”

行政权的积极、主动 近代社会的“小政府” (部门管得少)

d. 军事问题

宪法保留原则

要经议会的批准

开庭前不能见到当事人

可以由行政机关负责

增强了议会权力，利于对政府的监督

(政府只是公民的雇员和仆人)
目前人大的权力还需加强

议会中心主义：宣战、媾和、招募军队等重大军事问题

军队指挥、统帅权：国家元首、政府首脑等机构

军队国家化、政治中立

(3) 近代立宪主义宪法的影响

A. 确立了新型的国民与权力的关系

国民主权、人民主权

B. 促进了西方各国经济的高速发展

私有财产的保护 自由市场与自由放任 契约自由

马克思：资本主义在一百多年创造的财富超过了以往几千年的总和

C. 精神自由促进了科学技术、文学艺术等人类精神

文明领域的极大发展 表达自由、科学研究自由、大学自治与学术自由

D. 阴暗面

a. 严重的性别歧视

女性无政治权利、无民事行为能力 女性在现代社会才获得选举权

b. 严重的贫富分化、劳工阶层生存状况恶劣、劳资关系紧张

自由放任的后果：高失业率、低工资、大量使用童工；平均寿命下降

3. 近代德、日宪法（外表型立宪主义宪法）合法化危机

(1) 概况

徒有其表的立宪主义，并未真正实行分权 “自上而下”改革的产物

1889年《大日本帝国宪法》1850年《普鲁士宪法》

背景：日本的“脱亚入欧” 普鲁士统一德意志民族

通过立宪实现“富国强兵”，进入先进国家行列

(2) 特征

a. 君主主权下的立宪主义

君主主权是宪法的基本原则

b. 君主权力广泛而集中

行政权、与国会共同行使的立法权、立法否决权，名义上的司法权，宣战和媾和权

c. 臣民的权利

由法律授予的权利：与人权观念相左——人权：先于国家、与生俱来的权利

“凡是宪法没有规定的权利，均非臣民的权利”

“凡是宪法没有规定的权力，均推定属于天皇”

4. 现代立宪主义宪法

以近代立宪主义宪法为渊源，试图克服其阴暗面，在改良的基础上形成

现代主要西方国家的宪法（美、德、法、英、日等国）

(1) 社会国家观念的确立

自由国家——社会国家（福利国家） [夜警国家（守夜人）——超级保姆]

从消极无为的国家到提供生存福祉的国家（采取积极行动，提供生活条件和安全感）

对经济自由的限制：

为了缓和贫富分化、维护公共利益，对契约自由进行限制，劳动条件法定主义，反垄断

作为调节社会财富分配的税收政策

(2) 社会权的保障

人权的发展：自由权 → 社会权

消极的权利 → 积极的权利

主要内容：生存权——福利权？受教育权 劳动者的保障权

衣食住行、物质生活保障

国家有义务让本国国民受到一定教育，根据其财政能力和对教育的重视程度而定

不平等与政治

民主基础薄弱，女性人格附属与父亲或者丈夫 合理的性别歧视

工业革命—机器取代工作岗位

政府消极自由，自由放任
劳动权益完全没有保障

工人运动兴起，马克思主义传播

最终决定权在国王/天皇

1848年法国宪法 1849年德国基本法 1890年日本宪法

1946年日本宪法

消极自由—积极行动

垄断导致行业自由度下降，如将大公司分解

要为劳动者提供安全等必要保障 为公司形成市场竞争格局

靠政府创造，国家采取积极行动为国民提供福祉，如医疗保障制度、失业救济金制度等

调节社会财富分配已
对弱者保护对强者限制
主要针对富人

黑格尔哲学影响，财产是人性的客观体现是承担社会责任的担保

(3) 参政权的发展 (选举权、被选举权) 关系到参政能力

近代宪法：限制条件——财产、教育程度、性别

现代宪法：普选制 限制条件——年龄、国籍、精神病 直接选举

效果：

无阶级革命 缓和社会矛盾，使得劳工阶层及其政党获得参政机会，消解了资本主义的合法化危机
许多共产主义政党转变为社会民主党 (作为西方宪法的参与者)

(4) 加强自由权的保护

美国宪法上的“严格审查基准”——表达自由、精神自由的保护

刑事程序中对人身自由的保障——米兰达忠告 沉默权

(5) 权力分立制的改组

现代宪法：三权之间的严格分工削弱

行政权的扩张 政府获得立法权 专业性立法、议会立法的低效率

(6) 违宪审查制度的普遍化

政府权力的扩张颠覆了传统的权力分立观念，以违宪审查制度加强防范

司法化违宪审查：核心内容——立法的合宪性，针对政府立法和国会立法

美国式的违宪审查：普通法院 德国式宪法法院

(7) 军事问题

普遍立场：放弃战争 为了和平甚至可以放弃部分主权 战争权是主权国家的体现

1946 年日本宪法 1949 年德国基本法 日本和德国的战争权受到限制，只允许有自卫队代替军队

5. 社会主义宪法 一 理解中国宪法的基础，但不能等同

肇始于 1871 年的巴黎公社

1936 年、1977 年的苏联宪法 中国的 1954 年宪法，1975 年宪法，1978 年宪法

当下中国的宪法并非典型的苏联式的社会主义宪法 受其影响，中国现代社会主义宪法

(1) 人民主权原则：最高权力机关 [不是国民主权] 一 宪法制度下没有任何人可以认定为主权者，最高权力机关 (全国人大) 代表民意行使主权

(2) 民主集中制与议行合一 反对权力分立 (尤其是美国式的三权分立)

(3) 多种多样的自由权与社会权，但无经济自由权 一 计划经济

(4) 宪法基本权的主体：人民与敌人的划分 一 政治标准介入宪法

(5) 政党制度：先锋队组织 党领导国家

(二) 中国宪法历史 党的领导 + 人民主权

在严格意义上，中国的宪法与立宪还谈不上“历史”

1. 1949 年以前的中国宪法与立宪活动 1894 戊戌变法 一 中国宪法的萌芽

1908 年的《钦定宪法大纲》 1911 年的《重大信条十九条》 一 英国式的君主立宪制

1912 年的《中华民国临时约法》 1946 年《中华民国宪法》

2. 新中国的宪法 一 兼具苏联社会主义 (如全国人大) 和立宪主义国家宪法 (如保障人权) 的特点

1954 年宪法 1975 年、1978 年宪法 1982 年宪法 1954 一 由临时约法的更替

从 1988 年至 2018 年的五次宪法修改 推动经济增长就业 1975、1978 一 宪法修改，文革时期，犯了左倾错误，政治色彩浓厚

1988 年修正案：私营经济取得合法地位，允许土地使用权的流转

1993 年宪法修正案：社会主义市场经济，社会主义初级阶段理论

1999 年修正案：依法治国，社会主义法治国家 私营经济地位的进一步巩固

2004 年宪法修正案：保障人权 保护私有财产

2018 年宪法修正案：加强党的领导 监察委员会 合宪性审查

强化党的地位

党的领导由序言放到正文

2003 年加入 WTO 市场经济

国家 (保护私有财产，契约

自由 (民法中)